

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 103/2565	อัยการสูงสุด	โจทก์
	บริษัท ท.	ผู้ร้อง
	นาย ส. กับพวก	จำเลย

ป.อ. มาตรา 86

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502

มาตรา 8, มาตรา 11

ในทางใต้สวนไม่ได้ความว่า จำเลยที่ 1 มีอำนาจทำข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้บริษัท อ. ดำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงวันที่ 27 มีนาคม 2533 (ครั้งที่ 7) ด้วยตนเอง แต่เป็นอำนาจของคณะกรรมการของผู้ร้องโดยต้องเป็นไปตามมติของคณะกรรมการของผู้ร้อง จำเลยที่ 1 ไม่ได้มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือ รักษาทรัพย์สินใดตามหน้าที่ คงมีอำนาจบริหารกิจการของผู้ร้องตามที่คณะกรรมการของผู้ร้องมอบหมายเท่านั้น การเข้าทำสัญญาของจำเลยที่ 1 จึงเป็นไปตามมติของคณะกรรมการของผู้ร้องย่อมไม่เป็นความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 8 จำเลยที่ 1 คงมีความผิดตามมาตรา 11 เพียงบทเดียว

สำหรับจำเลยที่ 2 ได้ความว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้นำเอกสารประกอบวาระการประชุมที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารผลประโยชน์ ไปปรึกษาจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 เรียกนาย ส. และนาย ว. เข้าหารือที่ห้องทำงานของจำเลยที่ 2 โดยมีจำเลยที่ 2 ร่วมอยู่ด้วยและจำเลยที่ 2 เป็นผู้ปรับแก้ไขเอกสารดังกล่าวนำไปจัดพิมพ์ใหม่ ถือได้ว่าจำเลยที่ 2 มีส่วนร่วมกระทำความผิดดังกล่าวกับจำเลยที่ 1 ด้วย แต่จำเลยที่ 2 เป็น

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเป็นเลขานุการคณะกรรมการของผู้ร้องมีหน้าที่ดูแล
สำนักเลขานุการของผู้ร้องและจัดระเบียบวาระเรื่องที่จะนำเข้าประชุมคณะกรรมการ
มิได้มีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับจำเลยที่ 1 จึงมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการก
ระทำความผิดของจำเลยที่ 1 ดังกล่าว

โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 8, 11
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 นับโทษจำคุกของจำเลยที่ 1 ต่อจากโทษจำคุก
ของจำเลยที่ 1 ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อท.37/2559 ของศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ แต่จำเลยที่ 1 รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวเหมือนกับ
จำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

บริษัท ท. ผู้ร้อง ยื่นคำร้องและแก้ไขคำร้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน
16,753,393,546.99 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน
10,919,267,532.11 บาท นับถึงวันยื่นคำร้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ร้อง

จำเลยทั้งสองให้การในส่วนแพ่งขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและยกคำร้องของผู้ร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมในส่วน
แพ่งให้เป็นพับ

โจทก์ ผู้ร้อง และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพิพากษาลับว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 8 จำคุก 9 ปี จำเลยที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 8 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 จำคุก 6 ปี พยานหลักฐานของจำเลยทั้งสองที่ไต่สวนมาเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้คนละหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 6 ปี จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 4 ปี ให้นับโทษจำคุกของจำเลยที่ 1 ต่อจากโทษจำคุกของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อท.(ผ) 24/2560 ของศาลชั้นต้น ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 8,376,696,773.49 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 5,459,633,766.05 บาท นับถัดวันที่ผู้ร้องยื่นคำร้อง (ยื่นคำร้องวันที่ 29 สิงหาคม 2559) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมในส่วนแบ่งทั้งสองศาลให้เป็นพับ

โจทก์ ผู้ร้อง และจำเลยทั้งสองฎีกา

ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา บริษัท ร. ยื่นคำร้องขอสวมสิทธิเข้าเป็นผู้ร้องแทนบริษัท ท. ผู้ร้องเดิม ศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาต

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังเป็นยุติได้ว่า ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของผู้ร้อง มีอำนาจเสนอความเห็นในนามผู้ร้องต่อคณะกรรมการของผู้ร้องเพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานของผู้ร้อง ส่วนจำเลยที่ 2 ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของผู้ร้อง และเป็นเลขานุการคณะกรรมการผู้ร้อง มีหน้าที่ดูแลสำนักเลขานุการของผู้ร้อง และจัดระเบียบวาระเรื่องที่จะนำเข้าประชุมคณะกรรมการผู้ร้อง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2533 ผู้ร้องซึ่งเดิม

คือองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และบริษัท อ. ทำสัญญาให้ดำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าวมาแล้ว 6 ครั้ง ต่อมาวันที่ 7 สิงหาคม 2545 จำเลยที่ 1 ออกคำสั่งผู้ร้องที่ 12/2545 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมของคณะกรรมการผู้ร้อง โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 1. พิจารณากลั่นกรองเรื่องซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของผู้ร้องสั่งการให้นำเสนอคณะกรรมการผู้ร้องเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการดำเนินธุรกิจของผู้ร้อง และพิจารณาความถูกต้องในด้านกฎหมายและสอดคล้องกับข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ของผู้ร้อง รวมทั้งพิจารณาถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ร้อง 2. ชักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมของรองกรรมการผู้จัดการใหญ่... และ 5. ดำเนินการอื่นตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ของผู้ร้องมอบหมาย วันที่ 30 มกราคม 2544 บริษัท อ. มีหนังสือฉบับลงวันที่ 30 มกราคม 2544 ว่า ตามที่บริษัท อ. ได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัท จ. ว่าได้รับอนุญาตจากการสื่อสารแห่งประเทศไทยให้สามารถดำเนินการใช้เครือข่ายของบริษัท อ. ในการให้บริการให้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท จ. ได้ และบริษัท จ. มีความประสงค์จะขอใช้เครือข่ายของบริษัท อ. เพื่อให้บริการกับลูกค้าของบริษัท จ. ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544 เป็นต้นไปนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยทั่วไป และเกิดรายได้จากการใช้เครือข่ายของบริษัท อ. ดังกล่าวกับบริษัท อ. อันจะทำให้องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้รับส่วนแบ่งรายได้เพิ่มขึ้นจากรายได้ดังกล่าวด้วย บริษัท อ. จึงขอเปิดการให้บริการใช้เครือข่ายของบริษัท อ. ให้กับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท จ. ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544 เป็นต้นไป โดยบริษัท อ. จะส่งส่วนแบ่งรายได้ให้กับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยตามสัญญาต่อไป ซึ่งบริษัท จ. มีบริษัท อ. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ต่อมาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2545 บริษัท อ. มีหนังสือฉบับลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545 ว่าบริษัท อ. มีความประสงค์ที่จะอนุญาตให้ผู้ให้บริการรายอื่นสามารถเข้ามาใช้เครือข่ายร่วมในเครือข่ายของบริษัท อ. ได้ โดยคิดค่าใช้เครือข่าย

ของบริษัท อ. ในอัตรานาที่ละ 2.10 บาท ทั่วประเทศ และรายได้จากการใช้เครือข่าย
ของบริษัท อ. จะไม่นำมาใช้คำนวณค่าส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาร่วมงานของ
 บริษัท อ. ในทำนองเดียวกัน บริษัท อ. มีความประสงค์จะใช้เครือข่ายของผู้ให้
 บริการรายอื่น โดยบริษัท อ. จะจ่ายค่าใช้เครือข่ายให้กับเจ้าของเครือข่ายนั้นในอัตรา
 นาที่ละ 2.10 บาท เช่นเดียวกัน ค่าใช้บริการบริษัท อ. เรียกเก็บจากผู้ให้บริการหัก
 ด้วยค่าใช้เครือข่ายดังกล่าวแล้ว จะนำมาคำนวณเป็นส่วนแบ่งรายได้ให้กับผู้ร้องต่อ
 ไป ต่อมาในวันเดียวกันคณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมของคณะกรรมการ
 ผู้ร้องมีการประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวของบริษัท อ. มีข้อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 กับการคำนวณส่วนแบ่งรายได้บริษัท อ. เสนอว่า รายได้จากการให้ผู้บริการรายอื่นมา
 ใช้เครือข่ายของบริษัท อ. ยังต้องนำมาพิจารณาคำนวณส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญา
 อนุญาตให้ดำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับรายจ่ายของบริษัท อ. จาก
 การใช้เครือข่ายของผู้ให้บริการรายอื่น ถือเป็นภาระหน้าที่ของบริษัท อ. ที่จะต้อง
 ขยายเครือข่ายให้สามารถรองรับการให้บริการโดยบริษัท อ. จะเลือกวิธีการลงทุน
 สร้างโครงข่ายเพิ่มเติม หรือการใช้เครือข่ายของผู้ให้บริการรายอื่น ที่ประชุมมอบให้
 ฝ่ายบริหารผลประโยชน์ประสานงานกับบริษัท อ. ก่อนนำเสนอคณะกรรมการผู้ร้อง
 ต่อไป ตามบันทึกการประชุมครั้งที่ 2/2545 ต่อมาวันที่ 26 สิงหาคม 2545 บริษัท อ.
 มีหนังสือฉบับลงวันที่ 26 สิงหาคม 2545 ว่า บริษัท อ. ขอปรับหลักการใช้เครือข่าย
 ร่วมกัน หลังการเจรจาในรายละเอียดร่วมกับผู้ร้องเพิ่มเติมแล้วดังนี้ 1. ในกรณีที่ผู้
 ให้บริการรายอื่นเข้ามาใช้เครือข่ายร่วมในเครือข่ายของบริษัท อ. บริษัท อ. จะคิดค่า
 ใช้เครือข่ายของบริษัท อ. ในอัตรานาที่ละไม่เกิน 3 บาท ทั่วประเทศ และรายได้จาก
 ค่าใช้เครือข่ายของบริษัท อ. ดังกล่าวจะนำมาใช้คำนวณส่วนแบ่งรายได้กับผู้ร้องต่อ
 ไป และ 2. ในกรณีที่บริษัท อ. ไปใช้เครือข่ายร่วมของผู้ให้บริการรายอื่น บริษัท อ.
 จะจ่ายค่าใช้บริการเครือข่ายให้กับเจ้าของเครือข่ายนั้น ในอัตรานาที่ละไม่เกิน 3 บาท
 ทั่วประเทศ และรายได้จากค่าใช้บริการบริษัท อ. เรียกเก็บจากผู้ให้บริการหักด้วยค่า

ใช้เครือข่ายดังกล่าวแล้วจะนำมาคำนวณส่วนแบ่งรายได้ให้กับผู้ร้องต่อไป ต่อมาวันที่ 28 สิงหาคม 2545 คณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมของคณะกรรมการผู้ร้องมีการประชุมพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวของบริษัท อ. มีข้อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณส่วนแบ่งรายได้ที่บริษัท อ. เสนอซึ่งที่ประชุมมีความเห็นเป็น 2 แนวทาง คือ 1. ฝ่ายบริหารผลประโยชน์มีความเห็นว่า ตามสัญญาระหว่างผู้ร้องกับบริษัท อ. ข้อ 9 บริษัท อ. ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินบริการ และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์ทั้งหมด ประกอบกับสัญญาข้อ 16 บริษัท อ. ต้องจัดหาอุปกรณ์เพื่อให้บริการได้เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายบริหารผลประโยชน์จึงมีความเห็นว่าการคำนวณส่วนแบ่งรายได้ไม่ควรที่จะต้องหักด้วย ค่าใช้บริการเครือข่ายร่วมของผู้ให้บริการรายอื่น (ค่าโรมมิ่ง) ที่บริษัท อ. จ่ายให้แก่เจ้าของโครงข่ายอื่นเพราะเป็นภาระหน้าที่ของบริษัท อ. ตามสัญญาอยู่แล้ว นอกจากนี้ กรณีที่บริษัท อ. ทำการส่งเสริมการตลาดจนมีบางส่วนที่ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ที่เรียกเก็บจากผู้ให้บริการน้อยกว่าค่าโรมมิ่งที่บริษัท อ. ต้องจ่ายให้แก่เจ้าของโครงข่ายอื่น ก็จะมีผลกระทบทำให้ส่วนแบ่งรายได้ที่คำนวณมา มีผลติดลบได้ อย่างไรก็ดี หากจะคำนวณส่วนแบ่งรายได้โดยหักค่าโรมมิ่งที่บริษัท อ. จ่ายให้แก่เจ้าของโครงข่ายอื่นก่อนก็ควรมีมาตรการป้องกันผลกระทบในประเด็นนี้ไว้ด้วยเพื่อจะได้เกิดปัญหาโต้แย้งกันเกี่ยวกับวิธีการในการปฏิบัติติดตามมาภายหลัง เมื่อผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ร้องแล้ว และ 2. ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมของคณะกรรมการผู้ร้องมีความเห็นว่า โดยปกติการไปโรมมิ่งกับผู้ให้บริการรายอื่นจะใช้ในกรณีที่มีความจำเป็นเพราะรายได้ที่เรียกเก็บจากผู้ให้บริการจะต้องแบ่งให้กับเจ้าของโครงข่าย ทำให้มีรายได้น้อยกว่าการใช้เครือข่ายของตนเอง แต่ก็ประหยัดเงินลงทุนสร้างเครือข่าย และกรณีที่ผู้ประกอบการใช้เครือข่ายที่สร้างไว้ยังไม่เต็มขีดความสามารถ การให้ลูกค้าของผู้ให้บริการรายอื่นมาโรมมิ่งก็เป็นรายได้ที่เสริมเพิ่มขึ้น และอาจเทียบเคียงได้กับการโรมมิ่งระหว่างประเทศที่

มีการหักค่าใช้จ่ายจากอัตราค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ให้บริการ นอกจากนี้ในทางปฏิบัติ ผู้ประกอบการแต่ละรายอาจมีทั้งส่วนที่ให้ผู้อื่นร่วมใช้ และส่วนที่ไปใช้เครือข่ายของผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งในกรณีที่เครือข่ายของตนเองได้ถูกใช้เต็มที่แล้วและขยายไม่ได้ การไปใช้เครือข่ายของผู้อื่นก็ทำให้เกิดรายได้พิเศษเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และในทางเทคนิคสามารถตรวจสอบการโรมมิ่งได้ ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายบริหารผลประโยชน์ปรับเอกสารวาระโดยนำข้อพิจารณาของที่ประชุมมาพิจารณาและใช้ประโยชน์ แล้วนำเสนอคณะกรรมการผู้ร้อง โดยเร็วต่อไป ตามบันทึกการประชุมครั้งที่ 3/2545 ต่อมาวันที่ 29 สิงหาคม 2545 ฝ่ายบริหารผลประโยชน์จัดทำร่างวาระตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมของคณะกรรมการผู้ร้องเพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ร้อง โดยจัดทำความเห็นของผู้ร้องในส่วนที่เกี่ยวกับการคำนวณส่วนแบ่งรายได้ที่บริษัท อ. เสนอว่า 3.1 ข้อสัญญาที่เกี่ยวข้อง สัญญาข้อ 9 กำหนดว่า บริษัทต้องเป็นผู้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์ทั้งหมด สัญญาข้อ 16 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดหาอุปกรณ์ Cellular 900 เพื่อให้เปิดบริการได้ตามประมาณการลงทุน แผนการติดตั้งและสามารถบริการได้เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการและต้องให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และสัญญาข้อ 30 กำหนดในเรื่องการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเป็นอัตราร้อยละของรายได้และผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทพึงได้รับในรอบปีก่อนหักค่าใช้จ่ายและค่าภาษีใด ๆ และ ข้อ 3.2 ว่า ค่าใช้เครือข่ายร่วมกัน (โรมมิ่ง) ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามข้อกำหนดในสัญญาข้อ 9 และข้อ 16 รวมถึงการจ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้ผู้ร้องตามสัญญาข้อ 30 รายได้ที่นำมาคำนวณต้องเป็นรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายและภาษีใด ๆ วันที่ 30 สิงหาคม 2545 จำเลยที่ 1 เรียกนายสุวิทย์ และนายวรุธ ฝ่ายบริหารผลประโยชน์เข้าหาหรือที่ห้องทำงานของจำเลยที่ 2 โดยมีจำเลยที่ 2 ร่วมอยู่ด้วย จำเลย

ที่ 2 เป็นผู้ปรับแก้ไขเอกสารดังกล่าว แล้วส่งให้นายพิชัย ผู้จัดการส่วนเลขานุการ คณะกรรมการผู้ร่อนนำเอกสารวาระดังกล่าวไปปรับแก้ไขใหม่โดยไม่มีส่วนความเห็นของผู้ร่อนที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารผลประโยชน์ข้างต้นและมีเพิ่มเป็นข้อ 3.2 ว่า

เนื่องจากบริษัท อ. ให้บริการโดยได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่เพียง 7.5 MHz ตามที่ผู้ร่อนได้รับการจัดสรรมา ขณะที่ Operator รายอื่น 3 ราย รวมกันได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่รวมกันมากถึง 75 MHz ทำให้บริษัท อ. มีขีดความสามารถของโครงข่ายจำกัดกว่า Operator รายอื่น และขณะนี้ก็ได้วางโครงข่ายเต็มทีมากที่สุดในการบรรดาผู้ให้บริการทั้งหมดที่มีในปัจจุบันและเต็มความสามารถทางเทคนิคที่จะจัดพื้นที่บริการได้ตามคลื่นความถี่ที่ได้รับการจัดสรรแล้ว ทำให้เกิดสภาพมีพื้นที่ที่ไม่สามารถตั้งสถานีฐานรองรับการบริการได้ ประกอบกับผู้ใช้บริการของบริษัท อ. ที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก หากจะขยายเพิ่มเติมก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้ร่อนที่จะต้องจัดหาความถี่เพิ่มเติมให้ ซึ่งไม่สามารถทำได้ จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการใช้โครงข่ายร่วมกับผู้ให้บริการรายอื่น เพื่อลดข้อจำกัดทางเทคนิค ดังนั้น ในหลักการผู้ร่อนก็ควรร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้โครงข่ายร่วมในฐานะผู้รับผิดชอบจัดหาคลื่นความถี่ให้กับคู่สัญญา และข้อ 3.3 ว่า เนื่องจากการใช้โครงข่ายร่วมกันเป็นกรณีที่ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการในพื้นที่ปกติ ไม่สามารถใช้ได้ในโครงข่ายของตนเอง การที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการนอกพื้นที่บริการได้ทำให้เกิดรายได้พิเศษเพิ่มขึ้นจากขอบเขตบริการปกติ ดังนั้นในกรณีที่บริษัทผู้ได้รับอนุญาตไปใช้โครงข่ายอื่นเพื่อทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นในพื้นที่นอกเขตบริการซึ่งไม่เคยมีรายได้จึงเป็นประโยชน์ทั้งตัวผู้ใช้บริการและทำให้การร่วมให้บริการระหว่างผู้ร่อนและบริษัทผู้ได้รับอนุญาตได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากรายได้ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี เนื่องจากรายได้พิเศษดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เกิดจากโครงข่ายของตนเอง จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการใช้โครงข่ายของผู้ให้บริการรายอื่นด้วย ดังนั้น ตามข้อเท็จจริงรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษดังกล่าว เมื่อนำมาแบ่งรายได้โดยหักค่าใช้จ่ายก่อนก็น่าจะยอมรับได้

ต่อมาวันที่ 5 กันยายน 2545 คณะกรรมการผู้ร้องประชุมและอนุมัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณส่วนแบ่งรายได้ตามที่บริษัท อ. เสนอ คือ 1. กรณีที่ผู้ให้บริการรายอื่นมาใช้เครือข่ายร่วม (โรมมิ่ง) กับเครือข่ายของบริษัท อ. ในอัตรานาที่ละไม่เกิน 3 บาททั่วประเทศ รายได้จากการใช้เครือข่ายของบริษัท อ. จะนำมาใช้คำนวณส่วนแบ่งรายได้ให้กับผู้ร้อง และ 2. กรณีบริษัท อ. ไปใช้เครือข่ายร่วม (โรมมิ่ง) ของผู้ให้บริการรายอื่น บริษัท อ. จะจ่ายค่าใช้เครือข่ายนั้น ในอัตรานาที่ละไม่เกิน 3 บาททั่วประเทศ รายได้จากค่าใช้บริการที่บริษัท อ. เรียกเก็บหักด้วยค่าใช้เครือข่ายดังกล่าวแล้วนำมาคำนวณส่วนแบ่งรายได้ให้กับผู้ร้องต่อไป ต่อมาวันที่ 20 กันยายน 2545 ผู้ร้องและบริษัท อ. ทำข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้ดำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ครั้งที่ 7) มีผลบังคับวันที่ 1 ตุลาคม 2545 วันที่ 30 กันยายน 2545 จำเลยที่ 1 พ้นจากการเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามสัญญาจ้าง และวันที่ 1 ตุลาคม 2545 จำเลยที่ 2 เกษียณอายุราชการ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐส่งมอบสำนวนการไต่สวนกรณีกล่าวหานายทักษิณ กระทำการอันเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองและพวกพ้อง ทำให้มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมาก หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควรสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่อันเป็นการร่ำรวยผิดปกติให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยอาศัยอำนาจตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 30 เรื่อง การตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ลงวันที่ 30 กันยายน 2545 ข้อ 11 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการณ์ของจำเลยทั้งสองมีเหตุอันควรสงสัยว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีการแก้ไขสัญญาอนุญาตให้บริษัท อ. ดำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ครั้งที่ 7) เพื่อ

อนุญาตให้ใช้เครือข่ายร่วมกันกับของผู้ให้บริการรายอื่น และอนุญาตให้หักค่าใช้จ่ายจากการใช้เครือข่ายร่วมกันก่อนนำมาคำนวณส่วนแบ่งรายได้ให้แก่ผู้ร้อง

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองในประการแรกว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ เห็นว่า แม้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 84 ที่ใช้อยู่ในขณะนั้น จะบัญญัติให้การกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ผู้กล่าวหายื่นคำกล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เกินสองปีก็ตาม แต่มาตรา 88 ก็บัญญัติไว้ว่า เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับคำกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 84 หรือมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการตามหมวด 4 การไต่สวนข้อเท็จจริง ดังนั้น กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีเหตุอันควรสงสัยว่า จำเลยทั้งสองกระทำความผิดคดีนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ย่อมมีอำนาจไต่สวนข้อเท็จจริงได้โดยไม่ต้องคำนึงว่า จำเลยทั้งสองพ้นจากตำแหน่งมาเกินกว่าสองปีแล้วหรือไม่ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสอง

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองต่อไปว่า ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้ดำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ครั้งที่ 7) นั้น ขัดต่อสัญญาอนุญาตให้ดำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นสัญญาหลักหรือไม่ เห็นว่า สัญญาหลัก ข้อ 9 ระบุว่าบริษัท (บริษัท อ.) ต้องเป็นผู้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ และรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทั้งหมด ข้อ 12 ระบุว่า การดำเนินงานตามสัญญานี้ไม่ว่าการบริหาร การหาผู้ให้บริการ การโฆษณาหรือการทำนิติกรรมใด ๆ กับบุคคลภายนอกหรือผู้ให้บริการก็ดี บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการเองในนามบริษัท

บรรดาภาระผูกพันทั้งหลายที่บริษัทมีต่อบุคคลภายนอก องค์การ ท. จะไม่รับผิดชอบ ทั้งสิ้น และข้อ 30 ระบุว่าบริษัทต้องจ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนให้ องค์การ ท. เป็นรายปี ตามหลักประกันขั้นต่ำ หรืออัตราร้อยละของรายได้หรือผลประโยชน์ใด ที่บริษัทพึงได้รับในรอบปีก่อนหักค่าใช้จ่ายและค่าภาษีใด ๆ ทั้งสิ้น จำนวนไหน มากกว่าให้ถือเอาจำนวนนั้น จากข้อสัญญาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการดำเนินการตาม สัญญาของบริษัท อ. ไม่ว่าจะมียears ค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือค่าภาษีเกิดขึ้น บริษัท อ. จะต้อง เป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น ไม่อาจจะนำมาหักค่าใช้จ่ายและค่าภาษีดังกล่าวออกก่อน ได้ ดังนั้น กรณีที่บริษัท อ. ไปใช้เครือข่ายของผู้บริการรายอื่น บริษัท อ. ก็จะต้องรับ รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น โดยไม่อาจตีความเป็นอย่างอื่นไปได้ ข้อตกลงต่อท้าย สัญญาอนุญาตให้ดำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ครั้งที่ 7) ที่ยอมให้บริษัท อ. หักค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการรายอื่นก่อน จึงขัดต่อสัญญาหลัก

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองต่อไปอีกว่า จำเลยทั้งสองกระทำ ความผิดตามฟ้องหรือไม่ ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า ตามรายงานการประชุมคณะ กรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมของคณะกรรมการผู้ร้องครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2545 ในวาระที่ 4.2 ที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอของบริษัท อ. แล้วมี ความเห็นเป็นสองแนวทาง โดยแนวทางแรก ข้อ 2.1 เป็นความเห็นของฝ่ายบริหาร ผลประโยชน์ ส่วนแนวทางที่สอง ข้อ 2.2 เป็นความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรองวาระการประชุมของคณะกรรมการผู้ร้อง เมื่อคณะกรรมการกลั่นกรอง วาระการประชุมของคณะกรรมการผู้ร้องครั้งที่ 3/2545 มีมติควรนำเสนอคณะ กรรมการผู้ร้องพิจารณาตามหลักการที่บริษัท อ. เสนอโดยมีมาตรการป้องกันผลกระทบ ตามที่ฝ่ายบริหารผลประโยชน์เสนอไว้ด้วย การที่นายวรุฑ ทำเอกสารวาระใน ทำนองไม่เห็นด้วยกับการคำนวณส่วนแบ่งรายจึงไม่ถูกต้องเพราะที่ประชุมคณะ กรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมของคณะกรรมการผู้ร้อง ได้มีการปรึกษาหารือ กันในเรื่องนี้จนได้ข้อยุติและมีมติโดยให้นำเสนอความเห็นที่แบ่งออกเป็นสอง

แนวทาง ทั้งความเห็นของฝ่ายบริหารผลประโยชน์ที่ไม่เห็นด้วยกับการให้หักค่าใช้จ่ายในการโรมมิ่งก่อนนำมาคำนวณส่วนแบ่งรายได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการผู้ร้อง เพื่อพิจารณา ซึ่งนายวรุฑก็เห็นพ้องในมติดังกล่าวด้วย ดังนั้น การที่นายวรุฑจัดทำเอกสารนำเสนอวาระที่มีเพียงความเห็นของฝ่ายบริหารผลประโยชน์ที่ไม่เห็นด้วยกับการให้หักค่าใช้จ่ายในการโรมมิ่งดังกล่าวจึงต่างไปจากมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมของคณะกรรมการผู้ร้อง เมื่อจำเลยที่ 1 ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ของผู้ร้องและประธานคณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมของคณะกรรมการผู้ร้อง ทราบจากจำเลยที่ 2 ถึงความไม่ถูกต้องดังกล่าว และยังคงเพิกเฉยหรือละเลยไม่แก้ไข ปล่อยให้มีการจัดทำเอกสารวาระที่ต่างไปจากมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการผู้ร้องอาจเกิดความเสียหายต่อผู้ร้องได้ ดังนั้น การที่จำเลยทั้งสองเรียกฝ่ายบริหารผลประโยชน์คือนายสุวิทย์ และนายวรุฑ มาหารือจนได้ข้อสรุปให้ปรับแก้เอกสารวาระให้ตรงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมของคณะกรรมการผู้ร้องครั้งที่ 3/2545 ย่อมเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจ้างบริหาร ข้อ 2 ที่จะต้องบริหารกิจการของผู้ร้องให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ คำสั่งของผู้ร้อง และดำเนินงานอื่น ๆ ในทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อผู้ร้อง แม้ว่าการปรับแก้เอกสารวาระ จำเลยที่ 1 จะได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมไปจากมติที่ประชุมว่า บริษัท อ. มีผู้ให้บริการจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถวางโครงข่ายเพิ่มได้อีก จำเป็นต้องไปใช้โครงข่ายร่วมกันของผู้ให้บริการรายอื่น ผู้ร้องควรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้โครงข่ายในฐานะผู้รับผิดชอบจัดหาคลื่นความถี่ให้บริษัท อ. การคำนวณส่วนแบ่งรายได้ให้ผู้ร้องหลังจากหักด้วยค่าใช้จ่ายโครงข่ายร่วมกัน (โรมมิ่ง) น่าจะยอมรับได้และไม่ขัดต่อสัญญาหลักก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริงซึ่งมีการหยิบยกขึ้นหารือกันในคณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมแล้วอันจะช่วยให้การพิจารณาปัญหาดังกล่าวชัดเจนขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะ

กรรมการผู้ร้อง ซึ่งมีได้เป็นการบิดเบือนหรือทำให้มติดีที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมของคณะกรรมการผู้ร้องครั้งที่ 3/2545 เปลี่ยนไปแต่อย่างใด
จำเลยที่ 1 ไม่ได้ปิดบังข้อเท็จจริงความเห็นของฝ่ายบริหารผลประโยชน์ ทั้งไม่ใช่
หน้าที่ของจำเลยที่ 1 ที่จะต้องนำความเห็นของฝ่ายบริหารผลประโยชน์ดังกล่าว
เสนอต่อคณะกรรมการผู้ร้อง การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตาม
สัญญาโดยสุจริต นั้น เห็นว่า แม้นายวรุณจัดทำเอกสารนำเสนอวาระการประชุมที่มี
ความเห็นของฝ่ายบริหารผลประโยชน์ที่ไม่เห็นด้วยกับการให้หักค่าใช้จ่ายในการโรมมิ่ง
ซึ่งต่างไปจากมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมของคณะกรรมการ
ผู้ร้องดังที่จำเลยที่ 1 อ้างก็ตาม แต่เมื่อจำเลยทั้งสองเรียกฝ่ายบริหารผล
ประโยชน์คือนายสุวิทย์และนายวรุณมาหารือเพื่อให้ปรับแก้เอกสารวาระการประชุม
ดังกล่าวนั้น ก็ปรากฏว่ามีการปรับแก้เอกสารไม่ตรงกับมติที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองวาระการประชุมของคณะกรรมการผู้ร้อง ครั้งที่ 3/2545 ที่มีความเห็นเป็น
2 แนวทาง ตามข้อ 2.1 และ 2.2 ซึ่งในข้อ 2.1 เป็นความเห็นของฝ่ายบริหารผล
ประโยชน์ แต่ในร่างเอกสารเสนอคณะกรรมการของผู้ร้อง กลับไม่ปรากฏความเห็น
ของฝ่ายบริหารผลประโยชน์ตามข้อ 2.1 ซึ่งไม่เห็นด้วยกับการหักค่าโรมมิ่งที่บริษัท
อ. จ่ายให้กับเจ้าของโครงข่ายอื่นก่อนแต่กลับมีข้อความที่สนับสนุนข้อเรียกร้องขอ
บริษัท อ. ตามข้อ 3.2 และ 3.3 ซึ่งไม่เคยมีปรากฏอยู่ในเอกสาร ทั้งในข้อ 3.3 ยัง
ระบุในตอนท้ายว่า เมื่อนำมาแบ่งรายได้โดยหักค่าใช้จ่ายโครงข่ายก่อนก็น่าจะยอมรับ
ได้ ซึ่งข้อความข้อ 3.2 และ 3.3 เป็นข้อความที่โน้มน้าวให้คณะกรรมการของผู้ร้อง
คล้อยตามความเห็นสนับสนุนข้อเสนอของบริษัท อ. ข้างต้น แม้กรรมการของผู้ร้อง
แต่ละคนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถดังที่จำเลยที่ 1 อ้าง แต่การจะพิจารณาเรื่องต่าง
ๆ ให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด ย่อมจะต้องอาศัยข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งความเห็นของผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย หากทราบข้อโต้แย้งของฝ่ายบริหารผลประโยชน์ข้างต้นด้วยย่อม
ทำให้คณะกรรมการของผู้ร้องได้ขบคิดและใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจได้

อย่างรอบคอบยิ่งขึ้น การที่จำเลยที่ 1 ไม่นำความเห็นของฝ่ายบริหารผลประโยชน์ใส่ไว้ในเอกสารเสนอกรรมการผู้ร้อง ทั้งยังเพิ่มเติมความเห็นในทำนองสนับสนุนข้อเรียกร้องของบริษัท อ. เช่นนี้ ย่อมเป็นพฤติการณ์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ต้องการให้คณะกรรมการของผู้ร้องเห็นชอบตามข้อเสนอของบริษัท อ. โดยยอมให้หักค่าใช้จ่ายที่บริษัท อ. จ่ายให้ผู้บริการรายอื่นก่อนแล้ว จึงนำรายได้ส่วนที่เหลือมาคำนวณส่วนแบ่งรายได้ให้แก่ผู้ร้องอันเป็นการไม่รักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ร้อง จึงถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ของผู้ร้องโดยทุจริต ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 11 แต่ทางใต้สวนไม่ได้ความว่า จำเลยที่ 1 มีอำนาจทำข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้บริษัท อ. ดำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงวันที่ 27 มีนาคม 2533 (ครั้งที่ 7) ด้วยตนเอง แต่เป็นอำนาจของคณะกรรมการผู้ร้องโดยต้องเป็นไปตามมติของคณะกรรมการของผู้ร้อง จำเลยที่ 1 ไม่ได้มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์สินใดตามหน้าที่ คงมีแต่อำนาจบริหารกิจการของผู้ร้องตามที่คณะกรรมการของผู้ร้องมอบหมายเท่านั้น การเข้าทำสัญญาของจำเลยที่ 1 จึงเป็นไปตามมติของคณะกรรมการของผู้ร้องย่อมไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 8 จำเลยที่ 1 คงมีความผิดตามมาตรา 11 เพียงบทเดียว

สำหรับจำเลยที่ 2 ได้ความว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้นำเอกสารประกอบวาระการประชุมที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารผลประโยชน์ ไปปรึกษาจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 เรียกนายสุวิทย์และนายวรุณเข้าหาหรือที่ห้องทำงานของจำเลยที่ 2 โดยมีจำเลยที่ 2 ร่วมอยู่ด้วย และจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับแก้ไขเอกสารดังกล่าวนำไปจัดพิมพ์ใหม่ ถือได้ว่าจำเลยที่ 2 มีส่วนร่วมกระทำความผิดดังกล่าวกับจำเลยที่ 1 ด้วย แต่จำเลยที่ 2 เป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเป็นเลขานุการคณะกรรมการของผู้ร้องมีหน้าที่ดูแลสำนักเลขานุการของผู้ร้องและจัดระเบียบวาระเรื่องที่จะนำเข้าประชุมคณะ

กรรมการ มิได้มีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับจำเลยที่ 1 การกระทำของจำเลยที่ 2 จึงเป็นการให้ความช่วยเหลือ จำเลยที่ 1 ก่อนหรือขณะกระทำความผิด จำเลยที่ 2 จึงมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดของจำเลยที่ 1 ดังกล่าว และสมควรกำหนดโทษจำเลยทั้งสองเสียใหม่ให้เหมาะสมแก่สภาพความผิดของจำเลยทั้งสองสำหรับข้อเท็จจริงในคดีอื่นที่จำเลยทั้งสองอ้างมานั้น ก็มีข้อแตกต่างจากคดีนี้ จึงไม่อาจนำมาเทียบเคียงได้ ฎีกาอื่นของจำเลยทั้งสองเกี่ยวกับการกระทำความผิดของจำเลยทั้งสอง แม้จะวินิจฉัยต่อไปก็ไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลง จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย

มีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนตามฎีกาของจำเลยทั้งสองของโจทก์และผู้ร้อง ซึ่งจำเลยทั้งสองฎีกาในประการแรกว่า สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้ร้องขาดอายุความละเมิด นั้น เห็นว่า คดีนี้เป็นเรื่องเรียกร้องค่าเสียหายจากมูลความผิดที่มีโทษทางอาญา จึงต้องใช้อายุความทางอาญาซึ่งยาวกว่ามาใช้บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 วรรคสอง ซึ่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 11 มีอัตราโทษสูงสุดจำคุกสิบปี จึงมีอายุความ 15 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 (2) เมื่อจำเลยทั้งสองกระทำความผิดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2545 และโจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 คดีจึงไม่ขาดอายุความ

คงมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองของโจทก์และผู้ร้อง ซึ่งจะได้วินิจฉัยรวมกันไปว่า จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ร้องหรือไม่เพียงใด เห็นว่า เมื่อรับฟังได้ข้างต้นแล้วว่า จำเลยทั้งสองเป็นผู้กระทำความผิด การกระทำของจำเลยทั้งสองย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้อง โดยขาดประโยชน์ที่ควรได้รับจากบริษัท อ. แต่การแก้ไขสัญญาหลักตามข้อตกลงต่อท้ายสัญญาหลัก (ครั้งที่ 7) นั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ร้องด้วย จึงอาจจะ

ต้องมีผู้อื่นที่ร่วมรับผิดชอบนี้ด้วย จำเลยทั้งสองจึงไม่ควรต้องรับผิดชอบในค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวน ส่วนจำเลยที่ 2 แม้จะเป็นเพียงผู้สนับสนุนในความผิดทางอาญา แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องความรับผิดชอบทางแพ่ง ซึ่งตามพฤติการณ์แห่งคดี จำเลยทั้งสองต่างมีส่วนทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน จึงต้องร่วมรับผิดชอบเท่าๆ กัน และจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ศาลอุทธรณ์กำหนดมานั้น ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาโดยละเอียดแล้ว ซึ่งศาลฎีกาเห็นว่าเป็นจำนวนที่เหมาะสมแล้ว ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยบางส่วน ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังขึ้นบางส่วน ส่วนฎีกาของโจทก์และผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา มีการประกาศใช้พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 โดยมาตรา 3 และมาตรา 4 แห่งพระราชกำหนดดังกล่าวให้ยกเลิกความในมาตรา 7 และมาตรา 224 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้ความใหม่แทน เป็นผลให้ดอกเบี้ยยผิดนัดปรับเปลี่ยนจากอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 5 ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยยใหม่ที่กระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาบวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปี ทำให้ดอกเบี้ยยผิดนัดของค่าสินไหมทดแทนซึ่งเป็นหนี้เงินที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 ต้องปรับเปลี่ยนจากอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ปัญหาเรื่องอัตราดอกเบี้ยยขัดต่อกฎหมายหรือไม่เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยและกำหนดดอกเบี้ยให้ถูกต้องตามพระราชกำหนดดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 (5) ประกอบมาตรา 246 และมาตรา 252 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 40

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 11 ให้จำคุก 6 ปี จำเลยที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 11 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 ให้จำคุก 4 ปี เมื่อลดโทษให้คนละหนึ่งในสามแล้ว คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 4 ปี และจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 ปี 8 เดือน ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยกสำหรับดอกเบี้ยในต้นเงินค่าสินไหมทดแทนให้จำเลยทั้งสองชำระอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2559 จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 หลังจากนั้นให้ชำระอัตราร้อยละ 5 ต่อปี เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ร้อง แต่ทั้งนี้ หากกระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาเมื่อใด ก็ให้ปรับเปลี่ยนไปตามนั้น แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามขอ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ค่าฤชาธรรมเนียมในส่วนแพ่งชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ก่อกองศ์ สุวรรณจุฑะ-วายุรี วัฒนวรลักษณ-กฤตพงศ์ เอี่ยมวรเมธ)

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง - นายสุตสาคร เวชยชัย

ศาลอุทธรณ์ - นายสุพจน์ ดันไชย

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ